



לפני המפקחת על רישום מקרקעין, חיפה
יעל ליבוביץ

תיק תביעה מס': 218/12

בענין : ורנוביצקי יגאל
בלאנש בנטאטא גביון

מרח' אלישבע קפלן 20 דירות 6+7
טל': 050-7477058 , 04-8770885

הנתבעים

נ ג ד

1. בלזיצקי גרשון
בלזיצקי פרידה
מרח' אלישבע קפלן 20/8, ק. חיים, 26262

2. כרמלה אלפרון
אלישבע קפלן 20/5, ק. חיים, 26262

הנתבעים

פ ס ק - ד י ו

1. התובעים שהם, כל אחד בנפרד, בעלים של דירה בבית המשותף הגישו תביעה כנגד בעלים של שתי דירות אחרות בבית המשותף, בה עתרו לצו עשה אשר יחייב את הנתבעים להימנע מביצוע שינויים ברכוש המשותף ; להימנע מליצור יחידה תשיעית נפרדת בעליית הגג ; ולהורות על החזרת המצב לקדמותו לגבי שינויים שביצעו הנתבעים ברכוש המשותף.
2. השינויים שבוצעו ברכוש המשותף עפ"י הנטען כוללים : שינוי תכנות המעלית כך שתעצור בקומה השניה בכניסה אל עליית הגג ; הסרת קיר גבס שחסם את המעבר מהמעלית לעליית הגג ; יצירת דלת כניסה אל עליית הגג, והתקנת משטח עץ (דק) ברום חלל משותף לצורך מעבר מהמעלית לעליית הגג.
3. הבית נשוא ההליך נמצא ברח' אלישבע קפלן 20, קרית חיים, ומזוהה כחלקה 75 בגוש 11582 (להלן: "הבית/הבית המשותף"). בעבר היו בנויות על החלקה שתי דירות : אחת בקומת הקרקע ומעליה דירה נוספת בקומה הראשונה הנתבעים, ביחד עם חברת נ.צ.ג.ב. יזמות בע"מ (להלן: "החברה"), חתמו על הסכם שיתוף שיאפשר ל חברה להקים בבית 6 דירות נוספות שיחולקו בקיר משותף אל הדירות הקיימות הבית טרם נרשם כבית משותף אך אין מחלוקת כי הוא ראוי להירשם ככזה

טענות התביעה-

4. הנתבעים הם בעליה ומנהליה של החברה. החברה בנתה את הבית ככולל 8 דירות. במועד רכישת הדירות הוצגה לתובעים, ביחד עם הסכם הרכישה, תוכנית שהדגימה את דירת נתבעת מס' 2 ככוללת מדרגות פנימיות אל עליית הגג (להלן: "התוכנית המקורית"). בפועל, לאחר קבלת טופס 4, יצרו הנתבעים מדירת נתבעת מס' 2 שתי דירות נפרדות וגישה אל עליית הגג חיצונית לדירת הנתבעים, מתוך חדר המדרגות המשותף.
5. במועד רכישת הדירות הבטיח ה החברה לתובעים כי יבנה פטיו בחלל חדר המדרגות. לאחרונה הקימו שם הנתבעים משטח דק שישמש כגישה לדירה החדשה שייצרו באופן המסכל אפשרות בניית הפטיו.
6. במועד בו נכנסו בעלי הדירות לגור בבית היה חלל עליית הגג סגור, ללא דלת וללא גישה אליו, לא מתוך דירת הנתבעים ולא מכל מקום אחר, זאת בשונה מהתוכנית המקורית בו חוברה עליית הגג לדירת נתבעת מס' 2.
7. לאחר קבלת טופס 4 לבית, פתחו הנתבעים פתח אל עליית הגג, החלו להכשירה לשמש כדירה ובנו ברום החלל המשותף משטח דק שיחבר בין המעלית ליחידה החדשה.
8. בעקבות תלונות בעלי הדירות בבית על השינויים שביצעו הנתבעים ברכוש המשותף הגישו הנתבעים בקשה להיתר בנייה להקמת מדרגות ברכוש המשותף, שישמשו כמדרגות חיצוניות אל עליית הגג. עפ"י היתר הבניה נוצרת הלכה למעשה בעליית הגג יחידה נפרדת. הנתבעים נעדרים הסכמות בעלי הדירות בבית להוצאת חלקים מהרכוש המשותף וליצירת יחידה נפרדת.
9. לא ניתן לפצל דירה ללא קבלת הסכמות של בעלי הדירות בבית. הסכמת התובעים לא ניתנה. לחילופין יש לחייב את הנתבעים לשלם דמי וועד בגין יחידה זו.

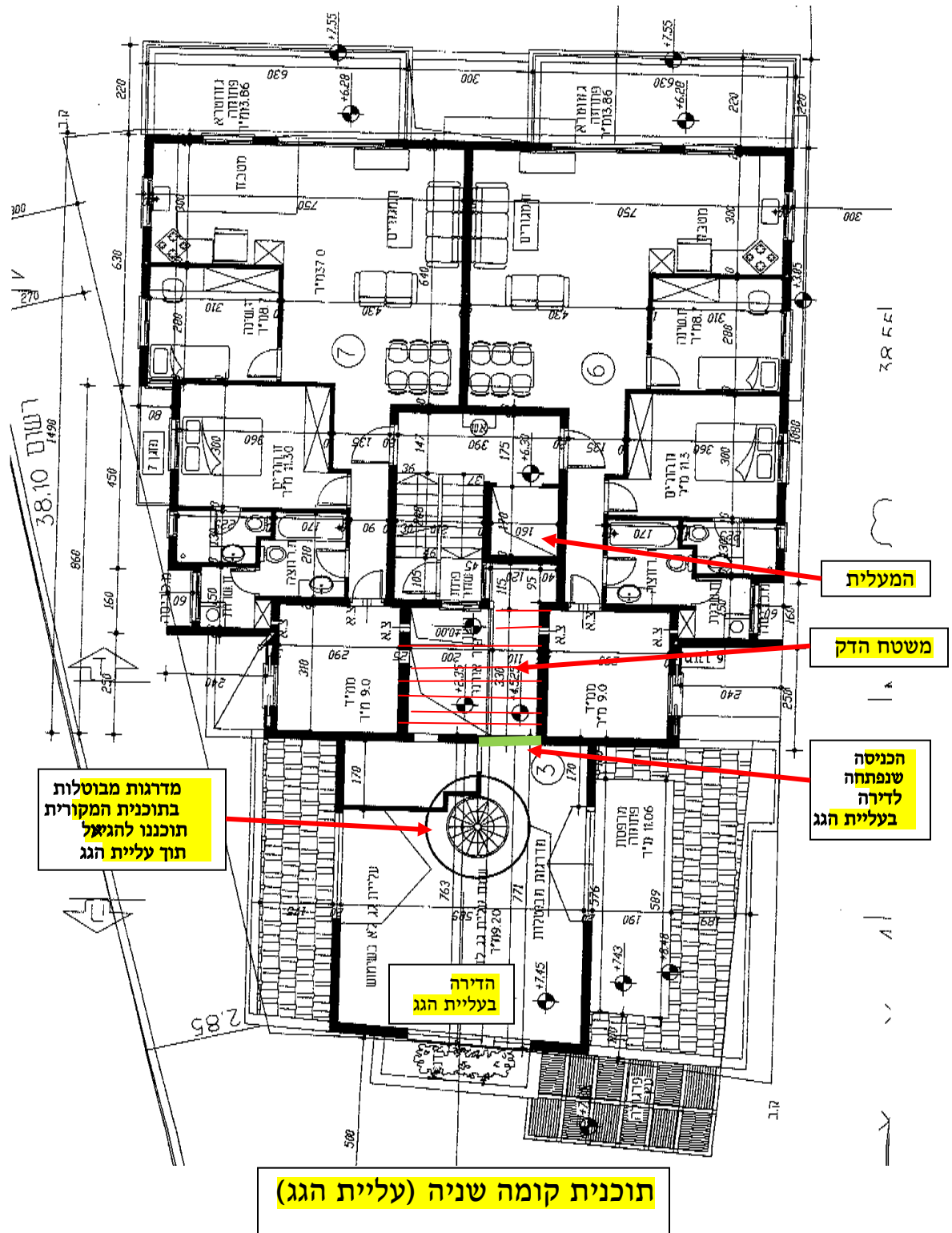
טענות ההגנה-

01. בהיתר הבניה שניתן בשנת 2008 כללה דירת הנתבעים דירה בקומה 2 שניה +עליית גג והמעלית כללה יציאה גם בקומת עליית הגג. גם התשריט שצורף להסכמי המכר של הדירות בבית הדגים את דירת הנתבעים ככוללת מדרגות לעליית הגג. בפועל בשל קושי כלכלי ביקשו הנתבעים שלא לפתוח את עליית הגג ולאור זאת הגישו תוכנית "מצב סופי" אשר בה עליית הגג נותרה חלל סגור. חלל זה, על אף שלא נפתח, נותר שייך מבחינה קניינית לנתבעים.

17. לאור העובדה שכבר במועד מכירת הדירות בבית ידעו כל בעלי הדירות בבית כי דירת הנתבעים כוללת עליית גג, אין הם צריכים את הסכמת בעלי הדירות בבית לשינויים היות והם בסך הכול משלימים את הבניה לפי התוכנית המקורית.
27. הנתבעים אכן הקימו משטח דק ברום חלל המדרגות משטח זה נבנה מבנייה קלה בהיותו זמני עד אשר יתקבל הי תר בניה שיאפשר בניית מדרגות שיחברו בין מפלס דירת נתבעת מס' 2 לבין עליית הגג.
37. בהסכם הרכישה הוצאו במפורש גם המעברים מהרכוש המשותף, ועל כן אין התובעים יכולים לטעון כי המדרגות המתוכננות להיבנות במעבר יותקנו ברכוש המשותף.
47. המעלית הוזמנה במקור כוללת 6 תחנות, לרבות היציאה בקומת עליית הגג. הנתבעים לא ביצעו במעלית כל שינוי.
57. בתחילת ינואר 2011 הסבו הנתבעים את עליית הגג למגורים ולשם כך בנו מעבר דק זמני מבנייה קלה שיאפשר גישה אל עליית הגג. במקביל החלו הנתבעים בהליך לקבלת היתר בניה לבניית גרם מדרגות שיקשר בין דירת הנתבעים לבין עליית הגג. בקשה זו אושרה ב- 3.10.11 ונמצאת בהליכים מתקדמים להוצאת היתר. לאחר שיתקבל היתר הבניה יוקמו המדרגות ויפורק משטח הדק הזמני. לאחר סיומן של העבודות תהווה עליית הגג חלק מדירת הנתבעים.

תוכנית שינויים ומצב סופי-

67. העובדות שאינן שנויות במחלוקת הן ש הנתבעים הגישו כחלק מהבקשה להיתר הבניה תוכנית מקורית בה הופיעה דירת נתבעת מס' 2 ככוללת עליית גג וכי במהלך הבנייה החליטו שלא לבנות את המדרגות המובילות אל עליית הגג ולא לפתוח כלל את עליית הגג. כפועל יוצא, הוגשה בשנת 2009 תוכנית שינויים ומצב סופי ששיקפה את הבניה כפי שנעשתה בפועל. מצאתי להביא בפסק דיני קטעים מתוך תוכנית שינויים ומצב סופי שהגישו הנתבעים, ביחד עם נ.צ.ג.ב יזמות בע"מ, ביום 22.12.09. על גבי התוכנית הוספו הערותיי וכן סימונים נוספים שלא נערכו עפ"י כללי מדידה תקינה אלא נעשו על ידי במיקום משוער וזאת ל שם הבהרה והמחשת המיקום המופיע בטיעוני הצדדים בלבד.



מהלך הדיון-

71. ביום 13.12.12 קיימתי ביקור במקום בנוכחות הצדדים כדי להתרשם באופן בלתי אמצעי מהנטען. להלן הנתונים אותם מצאתי רלוונטיים להליך:

(א) בבית 8 דירות. לדירת הנתבעים מס' 1, המצויה בקומת הקרקע, מגיעים דרך כניסה נפרדת ישירות מהרחוב. אל 7 הדירות הנותרות מגיעים דרך כניסה אחרת בה מצויות מדרגות ומעלית (להלן: "הכניסה הראשית").

(ב) דירת נתבעת מס' 2 נמצאת בקומה הראשונה, מעל דירת הנתבעים מס' 1. הגישה אליה היא דרך הכניסה הראשית ובאמצעות המדרגות או המעלית. הגישה לשש הדירות הנותרות בבית גם היא דרך הכניסה הראשית.

(ג) במפלס הקומה הראשונה, ביציאה מהמעלית, קיים מסדרון לכיוון מערב, ממנו מגיעים אל דירת נתבעת מס' 2. מסדרון זה כונה בתשריט לעיל "המעבר" והוא משמש רק את באי דירת נתבעת מס' 2. בסופו של מסדרון זה מצויה דלת הכניסה לדירת נתבעת מס' 2 ומצפון לו מצוי חלל לכל גובה הבית.

(ד) מעל דירת נתבעת מס' 2, בקומת עליית הגג, קיימת דירה נוספת לה כניסה נפרדת. הגישה אליה חיצונית לדירת נתבעת מס' 2. מאחר ובין המעלית המצויה בכניסה הראשית לבין עליית הגג היה קיים חלל שאינו מאפשר מעבר לדירה, בנו הנתבעים מעבר כמעין דק מהמעלית ועד לדירה בעליית הגג. מעבר זה נבנה מפרופילי מתכת עליהם הותקנה רצפת עץ דמוי דק והוא נבנה במפלס רצפת עליית הגג ברום החלל. בסופו של אותו משטח דק הותקנה דלת לאותה הדירה שבעליית הגג.

(ה) ניכר כי מדובר בשתי דירות נפרדות שאין ביניהן כל חיבור. ואולם, הנתבעים הדגישו בפני במקום כיצד תחבורה שתי הדירות לאחת לאחר שיקבלו את היתר הבניה המיוחל. עם ביצוע השינויים יוקמו מדרגות על גבי המעבר ותותקן דלת נוספת בקדמת המעבר באופן שלאחריה אפשר יהיה לבחור האם להיכנס לדירת נתבעת מס' 2 או לעלות במדרגות לקומת עליית הגג.

(ו) התרשמותי מהביקור הייתה כי גם לאחר שתותקנה המדרגות האמורות יהא מדובר בשתי דירות נפרדות ולא בדירה עם עליית גג. להלן הנתונים שנצפו בביקור המעידים על כך:

- קומת עליית הגג וכן דירת נתבעת מס' 2 מופרדות ותשארנה מופרדות בדלתות כניסה נפרדות בפתחה של כל דירה
- לדירה בקומת עליית הגג קיימים כל התנאים לשמש כדירה נפרדת והיא כוללת: מטבח, חלל ציבורי כמעין סלון וחדר שינה המכיל שירותים מקלחת. (אלו הודגמו בתרשים שהגישו הנתבעים).
- המדרגות המתוכננות מקומת הנתבעת אל קומת עליית הגג נמצאות מחוץ לדירת הנתבעת מס' 2. דלת כניסה נוספת שתותקן בקדמת אותן מדרגות

תהא מלאכותית, ונוספת על שתי דלתות פנימיות נפרדות לכל אחת מהדירות שלאחריה

81. בדיון שהתקיים לפניי ביום 18.12.12 העידו שני התובעים מטעם התביעה, ונתבעת מס' 1 העידה מטעם ההגנה. בסיום שלב ההוכחות סיכמו הצדדים טענותיהם בע"פ. בסיכומיהם חזרו הצדדים על טענותיהם שפורטו לעיל

תשתית נורמטיבית-

91. כפי שצוין לעיל, הבית נשוא ההליך אינו רשום כבית משותף אך מבחינה חוקית אין כל מניעה לרושמו ככזה. סעיף 77ב לחוק המקרקעין, התשכ"ט-1969 (להלן: "חוק המקרקעין") מחיל הוראות חוק מסוימות החלות על בתים משותפים גם על בתים שאינם רשומים כבתים משותפים וביניהן את הוראת סעיף 77א לחוק המקרקעין הכוללת הגדרה למונח "רכוש משותף". הגדרה זו היא שיורית ולפיה כרכוש משותף יחשבו "כל חלקי הבית חוץ מהדירות..." כלומר כל החלקים הנותרים לאחר שהוגדרו הדירות וההצמדות לדירות.

02. סעיף 6 לחוק המכר (דירות), התשל"ג-1973 (להלן: "חוק המכר") קובע הסדר ברור ומפורש לעניין האופן בו מוכר דירה נדרש לנהוג אם ברצונו להוציא חלקים מגדר הרכוש המשותף וזו לשונו:

"(א) המוכר דירה בבית משותף או בבית המיועד להירשם כבית משותף והתקנון שחל על הבית או שבדעתו להחיל על הבית מבטל או משנה הוראה של התקנון המצוי המתייחסת לענין מן הענינים המנויים להלן חייב לכלול במפרט או לצרף לחוזה המכר פרטים על אותו ענין; ואלה הענינים:

(1) הוצאת חלק מהרכוש המשותף;

(ב) מוכר שלא מסר פרטים על ענין מן הענינים המנויים בסעיף קטן (א) יראהו, על אף האמור בחוזה המכר, כמי שהתחייב שהוראות התקנון המצוי לגבי אותו ענין יחולו על הבית המשותף".

12. מטרת הוראה זו להבטיח כי כאשר רוכש אדם זכויות בדירה, הוא ידע אל נכון, כבר עובר למועד הרכישה, מהו היקף הזכויות הנרכשות על-ידיו לא רק לגבי יחידת הדיוור עצמה אלא גם לגבי חלקי הרכוש המשותף ועוד -

"מטרתו של חוק המכר (דירות) היא להביא לידיעת הקונה, בצורה ברורה ומובנת – וללא הסתתרות וערפול מאחורי אמירות כלליות וגורפות ומ בלי להבליע גופי דברים, שלהם משמעות כספית חשובה, בתוך ריבוי דברים טפלים ובלתי חשובים – מה הן כוונותיו האמיתיות של המוכר, ומה הן הזכויות אשר הוא, הקונה, רוכש הימנו... כדי להבטיח שאכן הובאו הדברים לידיעת הקונה והובנו על ידיו, חובה היא על המוכר לצרף לחוזה מיפרט ובו תיאור הדירה וכל הכלול בה... ואם מבקש המוכר לשנות מן התקנון המצוי בקשר לזכויות שבבית המשותף, חייב שינוי זה להופיע במפורש במיפרט הנ"ל או במסמך המצורף לחוזה ובו פרטים בקשר לשינוי זה. ייחוד והבלטה אלה מטרתם להסב את שימת לבו של הקונה לשינויים אלה

ראו ע"א 213/80 שמעון נ' ברוכים לז' (3), 808, בעמ' 813.

22. רציונל זה של חוק המכר (דירות), שעיקרו מתן הגנה לקונה מפני פגיעה בזכויותיו, בין היתר עקב גריעה מחלקי הרכוש המשותף בלא ידיעתו ובלא הסכמתו חל הן על מכר דירה בבניין שנרשם והן על בניין שטרם נרשם. הצורך בהגנה על זכויות הקונה תקף שבעתיים בבניין שטרם נרשם כאשר הסכם המכר נעשה זמן ניכר לפני הבנייה ובטרם קבלת החזקה בדירה בשל החשש כי בפרק הזמן בין ההתקשרות בהסכם לבין קבלת החזקה בדירה יחולו שינויים בלתי מ בוקרים בהיקף השטחים הנגרעים מהרכוש המשותף ומוצמדים ליחידות דיור ספציפיות. מכאן הדרישה בחוק המכר (דירות) כי גריעה מן הרכוש המשותף, בין בבניין רשום ובין בבניין שטרם נרשם, תהיה ידועה לקונה ומוסכמת עליו עובר להתקשרותו בהסכם המכר, ותקפותה המשפטית של גריעה זו מותנית בהסכמתו המלאה והמפורשת (וראו גם ע"א 750/88 אברהם רובינשטיין ושות', חברה קבלנית בע"מ נ' דיירי הבית המשותף ברח' קדושי קהיר 36-38 בחולון מד' (4), 861, בעמ' 869; ע"א 3902/98 מיאב חברה קבלנית לבנין בע"מ נ' סטולר, נד' (1), 849. על דברים אלו גם חזרו בע"א 374/08 ביחד עם ע"א 416/08 צדוק קטן נ' בורנשטיין ואח' וארז טסה נ' בורנשטיין ואח' שפורסם ביום 25.12.12.

דיון והכרעה-

32. השאלה הניצבת לפתחנו היא האם עליית הגג שייכת לנתבעת מס' 2, קרי, האם במועד מכירת הדירות לתובעים הדגימו הסכמי המכר והתשריט שהוצג בפניהם את דירת נתבעת מס' 2 ככוללת עליית גג, ואם כן, האם הודגם החיבור אל עליית הגג מתוך דירתה או מחוצה לה. בשלב שני, וככל שיימצא כי הנתבעים, כיום, מבקשים להקים מדרגות בתוואי שונה מהתוואי שהודגם בהסכם המכר ובתשריט שצורף לו תיבחן השאלה האם במועד בו נמכרו הדירות פעלו הנתבעים להוצאת המעבר (ראה מיקומו בתוכנית שצורף לעיל) מהרכוש המשותף בדרך שנקבעה בחוק, באופן שיאפשר להם כיום עשיית שימוש באותו המעבר לצורך הקמת מדרגות בו, והאם הותירו לעצמם הנתבעים, בהסכמי המכר, את האפשרות להגדיל את מניין הדירות בבית

42. בהתייחס לשאלה הראשונה העידה תובעת מס' 2, בעמ' 4 לפרוטוקול שורות 18-20 בענין כדלהלן:

" הדירה של גב' אלפרון בתוך התוכנית של הבניין המשותף היא הקוטג' הקדמי, זאת אומרת יש עליית גג מתוך הדירה שלה ולא מחוץ לדירה. כך תוכנן. במקום קוטג' עם עליית גג פשוט עשו מזה שתי דירות."

וראו גם עדותה בעמ' 5 שורות 8-9:

"השטח הוא השטח של הגב', אבל יש הבדל בין קוטג' לשתי דירות נפרדות ושתי משפחות נפרדות".

52. מעדות התובעת עלה כי במועד בו רכשה את דירתה ידוע היה לה כי קיים חיבור בין דירת נתבעת מס' 2 לבין עליית הגג, קרי, שעליית הגג שייכת ומחברת לדירת נתבעת מס' 2, אך אליבא דידא חיבור זה היה פנימי בבחינת "דירת קוטג'", בעוד שבפועל יצרו הנתבעים חיבור חיצוני שיוצר שתי דירות נפרדות ומצב זה אינו מקובל עליה.

62. חיזוק לעדותה נמצא גם בתוכנית שינויים ומצב סופי שהגישו הנתבעים לעיריית חיפה . (התוכנית שהובאה לעיל) תוכנית זו מדגימה את מיקומן של המדרגות שהיו מתוכננות להיבנות במקור, כמחברות בין דירת נתבעת מס' 2 לבין עליית הגג של דירתה . ניתן בנקל לראות כי מיקום המדרגות בתוכנית היה בתוך דירתה של נתבעת מס' 2 לאחר דלת הכניסה, ואלו הובילו אל תוך עליית הגג.

72. מהראיות ש הונחו לפניי ומהעדויות שוכנעתי כי במועד בו רכשו התובעים את דירתם הוצגה לפנייהם תוכנית דומה לתוכנית שינויים ומצב סופי, בה היו מדרגות פנימיות שחיברו את עליית הגג אל דירת נתבעת מס' 2. אלו ה מדרגות ש לצידן נרשם בתוכנית השינויים ומצב סופי "מדרגות מבוטלות".

82. האופי הכולל של היחידה שהקימו הנתבעים בעליית הגג מעלה כי כל חלק בה עונה באופן נפרד על הגדרת המונח "דירה" בחוק המקרקעין.

92. בע"א (ת"א) 1008/99 קבע בית המשפט את המבחנים לזיהוי דירה מפוצלת נפסק שם :

"... על מנת לבחון אם היח' הספציפית היא דירה יש לעמוד על קיום היסוד הפיזי שבה כנדבך אחד, והנדבך הנוסף הוא הכוונה, ובאופן אחר, ייעודה של הדירה. שניים אלה מצטרפים יחד להגדרת המושג דירה ... לא כל דירה חייבת לכלול גם חדר "מטבח" נפרד בנוסף לחדר מגורים. לא כל דירה חייבת לכלול גם חדר שירותים. יכול ואת הפונקציה של המטבח ישמש תקע חשמלי שאליו ניתן לחבר מכשירי חשמל שונים, יכול והדירה לא תכלול מטבח כלל. יכול והשירותים יהיו נפרדים ומשותפים עם דיירים אחרים וגם אז לא נשלל מחדר המגורים המהווה יחידה עצמאית את היותו דירה. שירותים נוספים הנדרשים לו לאדם ניתן לקבלם במסגרת אחרת ולאו דווקא באותה דיר ה.... גם כאן תמצוי כי הדירה היא מערכת חדרים או חדר בעלת כניסה נפרדת למגורי אדם ... אבן הבוחן הוא שימוש העצמאי של החדר או מערכת החדרים כיחידת מגורים, בבחינת חי הנושא את עצמו." (ההדגשה שלי – י.ל.)"

דברים דומים נקבעו בדע"פ 7014/08 (מיום 19.08.08) לאמור :

"המבחן אינו במספר דלתות הכניסה, חדרי המקלחת או חדרי השירותים המותקנים בדירה, כי אם בשאלה אם באורח מהותי איפשרה הוספתם או כל פעולה אחרת את פיצולה של הדירה ליחידות אחדות, עד כי היא חדלה לשמש יח' בודדת וכמוה באורח מעשי כמס' דירות השוכנות זו בצד זו."

03. העתקתן של המ דרגות שתוכננו מלכתחילה להיבנות מתוך דירת נתבעת מס' 2 אל תוך עליית הגג, אל מחוץ לשתי היחידות, ופתיחת דלת כניסה חיצונית נפרדת ליחידה שבעליית הגג, יצרה הלכה למעשה שתי יחידות נפרדות ועצמאיות כאלו שאף ניתן להשכירן כל אחת לבית אב נפרד.

13. אמור מעתה, לו היו הנתבעים מבקשים כיום לבנות את המדרגות באותו התוואי בו תוכננו במקור והודגמו לבעלי הדירות במועד הרכישה קרי, מתוך דירת נתבעת מס' 2 אל תוך עליית הגג, אזי לא היתה כל מניעה לכך והתובעים לא היו רשאים להתנגד לבניה. ואולם,

אין זה המצב. הנתבעים מבקשים לבנות את המדרגות מחוץ לדירת נתבעת מס' 2 על גבי המעבר המודגם לעיל.

23. בשלב שני, ולאחר שמצאתי כי מיקם המדרגות המתוכננות שונה ממיקומן בהסכמי המכר והמסמכים שצורפו להם, נדרשת אני ללשון הסכם המכר, המפרט והסכם השיתוף שצורפו לו, לבחון האם יש בהם כדי לענות על דרישת החוק והפסיקה לעניין הוצאת אותו המעבר מהרכוש המשותף והצמדתו לדירת מי מהנתבעים, ולשם בחינת זכותם של הנתבעים, אם לאו, להוסיף יחידה תשיעית בבית

33. באשר לחלקים שהוצאו מהרכוש המשותף תקבע בסעיף 16א להסכם כדלהלן:

"אם צוין בנספחים "א" ו/או "ד" להסכם, על הוצאת חלק /ים או שטח/ים מסוים /ים מהרכוש המשותף שבבנין ו /או על הצמדתו /ם לנכס/ים מסוים /ים, תהיה החברה זכאית להצמיד את אותו /ם חלק/ים או שטח /ים לכל נכס שתמצא לנכון, מפעם לפעם ויראו אותו חלק שהוצמד לנכס מסוים, כחלק מהנכס לשל כדבר וענין..
בנוסף ומבלי לגרוע מהאמור לעיל, הרוכש נותן את הסכמתו לכך, כי שטחי קרקע, מעברים, גינות, מחסנים וחניות, יוצמדו, כהצמדות מיוחדות, לנכס וליחידות אחרות במקרקעין, וזאת כמפורט בנספח ההצמדות המהווה נספח ד' להסכם זה..." (הדגשה שלי י.ל.)

43. נספח ד' להסכם זה מפרט בסעיף 4 את ההצמדות המיוחדות ואלו הן:

- 4.1" כל המחסנים המצויים בת שריט, למעט המחסן כאמור בפסקה 1.1 לעיל, המצמד לנכס.
- 4.2 כל שטחי החניה המצוינים בתשריט, למעט החניה כאמור בפסקה 1.2 לעיל, המוצמדת לנכס.
- 4.3 כל שטחי הקרקע של המקרקעין המסומנים בתשריט בצבע צהוב- אם וככל שסומנו בתשריט.
- 4.4 כל שטחי הגגות של הבנין המסומנים בתשריט יט בצבע אדום- אם וככל שסומנו בתשריט.
- 4.5 שטחים נוספים המסומנים בצבע ירוק- אם וככל שסומנו בתשריט."

53. ענינו הרואות כי המעבר לא נמנה עם השטחים שהוצאו במפורש מהרכוש המשותף והוצמדו לדירות. כבר מטעם זה לא מצאתי לקבל את טענת הנתבעים כי השטח בו בדעתם להקים מדרגות הוצא מהרכוש המשותף והוצמד דווקא לדירת נתבעת מס' 2. זאת ועוד, על הנתבעים שחפצים להוכיח כי שטח "המעבר" הוצא מהרכוש המשותף והוצמד לדירת נתבעת מס' 2 מוטל היה הנטל להוכיח כי שטח זה אכן הוצא מהרכוש המשותף. ככל שהנתבעים ביקשו להוכיח כי שטח זה נמנה עם ח' שטחים הנוספים" האמורים בסעיף 4.5 לעיל שנצבעו בתשריט בצבע ירוק, אזי, צריכים היו להגיש את אותו התשריט שצורף להסכם המכר המדגים את השטחים הצבועים בצבע ירוק. משלא עשו כן לא הרימו את הנטל המוטל עליהם להוכיח זאת. על הימנעות כזו קבע ביהמ"ש העליון בשורה של פס"ד כי:

"כלל הנקוט בידי בתי המשפט מימים ימימה, שמעמידים בעל דין בחזקתו, שלא ימנע מבית המשפט ראייה, שהיא לטובתו, ואם נימנע מהבאת ראיה רלבנטית שהיא בהישג ידו, ואין לו לכך הסבר סביר ניתן להסיק, שאילו הובאה הראיה, הייתה פועלת נגדו. כלל זה מקובל ומושרש הן במשפטים אזרחיים והן במשפט טים פליליים, וככל שהראיה יותר משמעותית, כן רשאי בית המשפט להסיק מאי-הצגתה מסקנות מכריעות יותר וקיצוניות יותר נגד מי שנמנע מהצגתה."

ראו ע.א. 548/78 שרון ואח' נ. לוי פד ל"ה(1) 736 בעמ' 760, ע"א 2275/90 לימה נ. רוזנברג פ"ד מז (2) 606.

63. משכך, בהינתן ש מדובר בשטח משותף, ולאור הוראות חוק המכר (דירות) והפסיקה שנסקרה לעיל, אני קובעת כי הנתבעים אינם רשאים לבצע בו שינויים או להקים בו מדרגות ללא שניתנה להם הסכמת בעלי הדירות בבית מאותו הטעם גם לא היו הנתבעים רשאים לבצע שינויים אחרים שביצעו ברכוש המשותף (דוגמת הסרת קיר הגבס ובניית משטח העץ), ללא שהקדימו וקיבלו הסכמות בעלי הדירות בבית

73. ויוער, אפילו הייתי מוצאת כי המעבר הוצא מהרכוש המשותף והוצמד לדירת נתבעת מס 2 לא היה בכך כדי להתיר הקמת המדרגות שם שכן הקמת מדרגות שם יוצרת הלכה למעשה שתי דירות נפרדות לחלוטין המאפשרות מגורים של בתי אב שונים, שכן עם בניית מדרגות אלו ניתן יהא להגיע אל עליית הגג ללא מעבר בתוך דירת נתבעת מס 2.

83. לעניין כמות הדירות שהתחייב הקבלן כי יהיו בבית עם סיומה של הבנייה ואבחן את הסכם המכר. במבוא להסכם המכר שנחתם בין החברה לבין תובע מס' 1 נקבע כי בבית תהיינה 8 יחידות וזו לשונו:

"והואיל: ועל המקרקעין בנוי כיום בית בן שתי דירות מגורים...
והואיל: ובכוונת החברה להקים על החלקה לאחר קבלת ההיתרים הנדרשים...בנין מגורים שיכלול 6 יח"ד, וכן את הדירות הקיימות".

גם בסעיף 1.2 למפרט הטכני שצורף כנספח להסכם המכר נקבעאמור:

"בבנין 8 דירות למגורים".

93. ההסכמים אם כן קבעו מפורשות כי בבית תהיינה 8 דירות בלבד. כבר מטעם זה הנתבעים אינם רשאים ליצור בבית דירה תשיעית ללא שהתובעים נתנו הסכמתם לכך

04. סיכום המקובץ לעיל מעלה כי הנתבעים לא היו רשאים ליצור בבית דירה תשיעית ולא היו רשאים לבצע את השינויים ברכוש המשותף אותם ביצעו

14. לגבי המעלית, לא מצאתי כי הנתבעים ביצעו שינוי בתכנות המעלית או בחלקיה. ההסכם לאספקת המעלית שהוגש מראה כי המעלית תוכננה מראש ככוללת תחנות. לאור האמור אינני עושה צו בעניין.

סוף דבר-

24. ניתן בזאת צו עשה שיחייב את הנתבעים, ביחד ולחוד, בתוך 90 יום מהיום, לפרק את פרופילי המתכת ומשטח הדק שנבנו במפלס רצפת עליית הגג ו כן לפרק את דלת הכניסה לחלל שבעליית הגג ו להחזיר המצב לקדמותו. הנתבעים גם יבנו, בתוך 90 יום מהיום, את קיר הגבס שפרקו באותה הקומה במיקום כפי שהיה קיים. כן ניתן בזאת צו מניעה קבוע שיאסור על הנתבעים, ביחד ולחוד, להקים מדרגות אל עליית הגג בשטח המעבר.

34. אני מחייבת את הנתבעים, ביחד ולחוד, לשלם לכל אחד מהתובעים הוצאות משפט ושכר בטלה בסך של 1,000 ₪. סכום שלא ישולם בתוך 30 יום יישא הפרשי הצמדה וריבית מיום הגשת התביעה (7.8.12) ועד התשלום המלא בפועל

ניתן בהעדר הצדדים ביוסכה' בשבט תשע"ג (5.2.13).

העתקים יישלחו לצדדים

יעל ליבוביץ

מפקחת על רישום מקרקעין